

0000329-24.2016.8.26.0334

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE

Comarca: Macauba

Foro: Foro de Macauba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... oportunidade em juízo:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Macauba

Foro de Macauba

Vara Única

Rua Sebastião Dib, 668, ., Centro - CEP 15270-000, Fone: (17) 3874-1908, Macauba-SP - E-mail: macauba@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo Digital nº:

0000329-24.2016.8.26.0334

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leiva Eliane Perpetua Pierini e outro

Vítima:

Maria Jose Tonholi Moura

Aos 10 de fevereiro de 2022, às 17:00h, na sala de audiência virtual da Vara Única do Foro de Macauba, Comarca de Macauba, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CAROLINA CASTRO ANDRADE, comigo Escrevente Técnico Judiciário, regularmente conectada à sala virtual e ao final subscrita, foi aberta a teleaudiência para instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram no lobby da sala virtual, com exitosa conexão, Dr. ANDRÉ LUÍS DE SOUZA, representante do Ministério Público, e Dra. Anny Vitoria Peres OAB 424291/SP, defensora do acusado. Presente também o réu CLEBER DA SILVA ALVES e a vítima e testemunha abaixo qualificadas:

MARIA JOSE TONHOLI MOURA, brasileira, aposentada, RG 26405156, pai Ricardo Tonholi, mãe Maria Jose Tonholi Moura, natural de Monte Aprazível-SP, Rua Manoel Ferreira Pinto, 578, Centro, CEP 15270-000, Macauba-SP;

MARIA APARECIDA ROSALES FERRARI, brasileiro, casado, RG 26293103, pai Antonio Rozales Moura Filho, mãe MARIA JOSE TONHOLI MOURA, nascido em 16/05/1958, natural de Macauba-SP, Fazenda Santa Barbara, Zona AZENDA SANTA BARBARA, ZONA RURAL, Macauba-SP.

Ausente a ré LEIVA ELIANE PERPETUA PIERINI.

Em seguida, pela MMª. Juíza foi explicado que, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência seria realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft.

Iniciados os trabalhos, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: A defesa apresentada pelo acusado toca em matéria de mérito e será com ele analisada. Isso porque a discordância da Defesa quanto à forma como os fatos ocorreram ou foram capitulados não justifica a rejeição da denúncia, tratando-se de matéria de mérito, que se submete à instrução probatória sob o crivo do contraditório. Também não estão presentes quaisquer das hipóteses legais que levariam à rejeição da denúncia (art. 395 do CPP) ou à absolvição sumária (art. 397 do CPP). Por tais motivos, ratifico a decisão que recebeu a denúncia.

Após identificação pessoal, através de documento original com foto, foram ouvidas a vítima acima qualificada e a testemunha MARIA APARECIDA, que foi ouvida sem ser compromissada por declarar ser filha da vítima.

A MMª. Juíza homologou a desistência de oitiva da testemunha ANTONIO ROSALES, como requerido pelo DD. representante do Ministério Público às fls. 463.

Em seguida, o réu foi interrogado, sendo-lhe previamente assegurado o direito de entrevista reservada com sua defensora, bem como efetuada a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal.

Não havendo mais provas a serem produzidas, o MM. Juiz determinou o início dos debates orais. Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por sistema audiovisual, sendo a mídia disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme prevê o Comunicado Conjunto nº 1350/2020.

Ato contínuo, a MMª. Juíza proferiu a seguinte sentença:

LEIVA ELIANE PERPETUA PIERINI e CLEBER DA SILVA ALVES foi denunciados como incursos no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Isso porque, segundo consta, no dia 3 de fevereiro de 2016, por volta das 17h, na Rua Manoel Ferreira Pinto, nº 578, Centro, nesta cidade e comarca de Macaúbal, o acusados, qualificados, respectivamente, a fls. 132 e 160, previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram para si, mediante fraude, a quantia de R\$ 1.530,00 na agência do Banco Santander e de R\$ 1.000,00 na agência do Banco do Brasil, da vítima Maria Jose Tonholi Moura, idosa com 83 anos.

Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: Maria José Tonholi Moura (vítima - fls. 9), Antonio Rosales Moura Filho (fls. 08), Maria Aparecida Rosales Ferrari (fls. 02) e José Geraldo Rodrigues Correia - (fls. 101).

Recebida a denúncia (fls. 213/214), o acusado foi citado pessoalmente (fls. 279) e apresentou defesa prévia (fls.384/386), por defensora nomeada (fls. 374), negando a prática do delito, pedindo absolvição e arrolando as mesmas testemunhas de acusação.

A acusada foi citada por edital (fls. 418) e o processo e a prescrição foram suspensos nos termos do art. 366 do CPP (fls. 424/425).

O recebimento da denúncia foi ratificado, sendo realizada audiência de instrução.

As partes apresentaram alegações finais oralmente. O Ministério Público pediu absolvição por falta de comprovação da autoria, enquanto a Defesa pediu absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A autoria e materialidade dos fatos restaram indiciariamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), termos de declarações depoimentos e interrogatório (fls. 09, 10, 91, 156, 188), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 13 e 14), autos de exibição e apreensão (fls. 44/46), fotografias (fls. 11/12 e 19/23), ofícios (fls. 25, 26 e 46) e quebra de sigilo de dados (Proc. 0000536-23.2016.8.26.0334 e 0000537-08.2016.8.26.0334 - apenso).

Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório não dá respaldo à acusação.

Conforme a denúncia:

Os denunciados foram até a agência do Banco do Brasil e, por várias vezes, tentaram sacar dinheiro da conta de Maria Jose e, na última, lograram subtrair a quantia de

R\$ 1.000,00 (ofício de fls. 17 e imagens de fls. 18/22 e 25). No Banco Santander lograram sacar a quantia de R\$ 1.530,00 (ofício de fls. 23 e imagens de fls. 24)

Enquanto os denunciados estavam no banco, a vítima percebeu que os cartões bancários, que estavam dentro do guarda-roupa, foram subtraídos. Assim, ela foi até a agência do banco Santander e Antonio, marido da vítima, até a agência do Banco do Brasil.

O denunciado Cleber foi encontrado dentro da agência do banco Santander, o qual disse à vítima que não sabia de nada e fugiu do local. Leiva não foi encontrada. Maria Jose e Antonio, seu marido, reconheceram os denunciados mediante fotografia (fls. 13/14).

Em diligências, foi constatado que os denunciados praticaram diversos golpes na região, cujo modus operandi era "benzer joias a pedido do pároco da cidade"

A vítima, Maria José Tonholi Moura, relatou que um casal foi até sua casa, dizendo-se agentes de saúde e os atendeu. Enquanto o homem fazia massagem nas pernas do falecido esposo da depoente, a mulher indagou sobre um cartão bancário grande, que a vítima disse não possuir. A vítima não reparou que a mulher estava atrás da depoente. Depois disseram que a massagem tinha acabado e quando a vítima percebeu seu quarto estava bagunçado e havia um cartão que não era seu. A vítima foi ao banco e ele estava lá sacando, enquanto ela estava em outro banco. As senhas estavam junto com os cartões. Na delegacia a vítima reconheceu mais ou menos. O vizinho viu o casal.

A testemunha Maria Aparecida Rosales Ferrari afirmou que a vítima relatou que os indivíduos, homem e mulher, disseram ser agentes de saúde. O homem ficou massageando o pai da depoente, enquanto a mulher perguntou sobre os cartões da vítima, tirou sua bolsa e trocou os cartões. A vítima foi até o banco e encontrou o homem sacando o dinheiro. A vítima se dirigiu ao Banco Santander e no Banco do Brasil estava a mulher. Os saques foram feitos em ambos. O vizinho viu o casal. Na delegacia mostraram vários casais e a vítima ficou em dúvida. Não sabe se o horário do saque correspondia ao horário em que o indivíduo foi localizado no banco.

Houve falecimento e desistência da oitiva das demais testemunhas (fls. 450 e 458). Em seu interrogatório, o acusado negou as acusações, dizendo que namorou a acusada, morava em Rio Preto, nunca esteve em Macaúbal nem tem relação com o golpe de benzer joias do padre.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que não há prova suficiente para atribuir a autoria do delito ao acusado.

Verifica-se nas fotografias que os supostos autores do fato estavam usando boné e óculos de sol na instituição financeira e, conforme a própria vítima e sua filha, a vítima não teve certeza quanto ao reconhecimento fotográfico dos acusados na Delegacia.

Assim, deixo de considerar o reconhecimento fotográfico dos acusados, inclusive em virtude do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que só deve ser admitido o reconhecimento pessoal com as formalidades previstas no art. 226 do CPP, que exige a comparação com outras pessoas, inviável também nessa oportunidade em juízo:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e

distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das conseqüências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, conseqüentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II).

7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias).

9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua conseqüente absolvição, ante a inexistência,

como se defluiu da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância).

12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)

Ante o exposto, com fundamento no art. 386, V, do CPP, ABSOLVO CLEBER DA SILVA ALVES da acusação de prática do delito previsto no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Custas na forma da lei.

Deixo de deliberar sobre a restituição dos bens apreendidos em virtude da suspensão do processo (art. 366 do CPP) quanto à acusada.

Declaro o trânsito em julgado nessa data, independentemente de certidão, diante do consentimento entre as partes acerca da absolvição.

Comunique-se ao IIRGD e expeça-se certidão de honorários. Após, archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ). Saem os presentes intimados.

Pelas partes foi dito que não há interesse em recorrer da sentença. Pela MMª. Juíza de Direito foi dito: "Homologo a renúncia manifestada pelas partes. Cumpra-se a sentença de acordo com seus comandos finais". Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo, assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito, através do Sistema SAJ, cujo conteúdo foi lido e aceito pelas partes e advogados. Certificada a presença dos mencionados na presente ata, deixo de cumprir o disposto nos artigos 145, III; 1.269 e 1.270, todos das NSCGJ do Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo. O referido é verdade e dou fé. Eu, Julia Campos Leite, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Documento assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a) de Direito Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE, nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.